

1516469-76.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516469-76.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516469-76.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2198134/2022 - 23º D.P. PERDIZES, 26275023 - 23º D.P. PERDIZES, 2198134 - 23º D.P. PERDIZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALLACE DE OLIVEIRA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

WALLACE DE OLIVEIRA SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Isso porque, no dia no dia 21 de julho de 2022, por volta das 15h30min, na Rua Rubens Porta Nova, altura do número 77, Barra Funda, nesta cidade e comarca, o acusado, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: a) 46 invólucros de cor roxa contendo cocaína, com peso total de 10,08 gramas; b) 38 invólucros de cor rosa contendo 15,6 gramas de cocaína; c) 33 trouxinhas de papel contendo 58,1 gramas de maconha; 24 pedras de crack com peso de 4,2 gramas; d) 12 embalagens de plástico contendo pedras de crack, com peso de 8,7 gramas, substâncias entorpecentes que

causam dependência química e física, além da quantia em espécie de R\$ 86,65 (oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Narra a denúncia que WALLACE, com vontade livre e consciente, trazia consigo, para fins de tráfico, as diversas porções de cocaína, crack e maconha, embaladas individualmente, prontas para o comércio, além da quantia em espécie de R\$ 86,65 (oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) proveniente da venda de drogas. Policiais militares realizavam patrulhamento no local, conhecido ponto de tráfico de entorpecentes, ocasião em que notaram a presença do acusado e viram que ele trazia consigo uma pochete e optaram por abordá-lo. Revistado, os policiais encontraram as diversas porções de entorpecentes e a quantia em dinheiro em notas trocadas, dentro da pochete que o acusado segurava. Formalmente interrogado, o acusado optou pelo silêncio.

Oferecida a denúncia de fls. 01/03, foi ela recebida por despacho no dia 22 de setembro de 2022 e agendou-se uma audiência de instrução e julgamento (dls. 85/89). O acusado foi citado (fls. 81) e apresentou-se defesa prévia (fls. 83).

Durante a instrução de causa, dois policiais foram ouvidos. O réu optou pelo silêncio.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia e não se opôs a concessão do redutor.

A Defesa requereu a absolvição com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Subsidiariamente, na primeira fase da dosimetria, a fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis. Na etapa intermediária, não há agravantes ou atenuantes. Na derradeira fase, a aplicação do redutor do § 4º da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo. Por fim, a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, a substituição desta por restritivas de direitos e a garantia do direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

Encontram-se nos autos, ainda, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 05/08); o auto de prisão em flagrante (fls. 04; 09); o auto de exibição e apreensão (fls. 18/19); o laudo pericial (fls. 25/29; 67/68; 69/72); bem como as folhas de antecedentes do acusado (fls. 38/40; 60).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls.18/19) e dos laudos de constatação provisória (fls. 25/29 ), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (fls.69/72), com resultados positivos para COCAÍNA e TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva.

Passo a transcrever os depoimentos colhidos em regular instrução.

O policial Eduardo reconheceu o acusado por tráfico de entorpecentes. Região bem conhecida na área da delegacia, frequentada por usuários. Ao passar pelo local viu um indivíduo com uma pochete. Ele estava com pessoas em volta que aparentemente estavam comprando. Estavam com camisetas de time de futebol e ele não percebeu que eram policiais. Já chegou e o pegou direto. A pochete estava com ele. Ele jogou a pochete dentro de um barraco o que foi presenciado pelo policial. Havia uma pequena quantia em dinheiro trocado, cerca de 100 reais. Havia cocaína, crack e maconha, embalados para venda. Ele disse que estava necessitado. Nunca o viu anteriormente. O parente ou o vizinho foi buscar os documentos dele próximo ao local onde foi preso. Não sabe porque não constou no

Policial Rodolfo também reconheceu o acusado de uma das prisões que efetuou por tráfico de entorpecentes. Trabalha no 3º DP. O local é conhecido por tráfico de drogas. De vez em quando faz diligências no local. O réu estava fazendo a venda de

drogas. Não entra carros só a pé. Entrou de um lado e o parceiro de outro. Quando o viu, ele estava sentado em um banco e viu que ele estava vendendo drogas. Estava distante mas dava para ver. A pochete estava próxima a ele e viu o momento em que ele jogou a pochete. As pessoas saíram correndo e não conseguiu pegar outra pessoa. Não se atentou em relação ao fato de não constar no seu depoimento que viu o acusado na veda de drogas. Não o conhecia antes dos fatos. Não havia denúncias sobre ele especificamente. Ele informou que morava ali próximo, uma moça disse que ia buscar o documento dele no barraco

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96).

É verdade que ambos, em juízo, declararam terem visto o acusado na pratica da mercancia o que não foi dito por ocasião da prisão em flagrante. Mas esse fato, por si só, não autoriza o reconhecimento de que ambos forjaram a droga contra a pessoa do acusado, que sequer conheciam. Pese a conduta deselegante e displicente do policial Ricardo por ocasião de seu depoimento, sua falta de urbanidade, a qual foi imediatamente percebida e devidamente corrigida por esta Magiostrada, não o tornou indigno de fé.

Não restam duvidas de que o acusado estava na posse do entorpecente que era destinado a venda, porque não se pode admitir que tamanha quantidade de entorpecente bem como a variedade destinava-se a uso proprio.

E nem se diga que o fato do acusado residir ali naquela comunidade seja um fator inibidor de sua conduta criminosa na medida em que ficou claro que ele ali residia sozinho e não com sua familia. Portanto, não havia qualquer freio inibitório ao acusado que ali residia, ao que tudo indica, sozinho.

Repito. A quantidade de etorpecente apreendida e a forma de acondicionamento, bem como a variedade das substancias, estão aindicar de forma mais que tranquila, atividade ilícita.

Por fim, Wallace optou pelo desejo de ficar em silencio., portanto, nada tenho a comentar sobre suas alegações.

Mas o fato é que a meu sentir, a prova autoriza o edito condenatório nos termos em que consta na denuncia.

Daí porque, afigura-se de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal. Por outro lado, ele é primário e não ostenta antecedentes. Nada a considerar em segunda fase.

Em terceira fase, na esteira das ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui maus antecedentes. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a prática delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno WALLACE DE OLIVEIRA SOUZA, RG: 58338806, CPF: 546.740.178-58, nascido em 09/05/2001, filho de Anderson Rodrigo Souza e Katia Gilmara De Oliveira, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, “caput” e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, “d”, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Decreto o perdimento do valor apreendido (fls.18/19). Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando acerca desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, ex vi do constante no art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/06; Transitada esta em julgado tornem concluso para a designação de data para audiência admonitória.

Publicada em audiência.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA